

1523099-85.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Ministro Félix Fischer; Ementa: "TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2127-

9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1523099-85.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523099-85.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Bernardino de Seixas Freitas

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Cesar Muller Valente

Vistos, etc.

Leandro Bernardino de Seixas Freitas, qualificado à fl. 16, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 22 de setembro de 2021, em período de calamidade pública, na Rua Ismael Neri, altura do nº 169, Santana, bem como no interior da residência situada em referido endereço, nesta cidade e Comarca de São Paulo, vendia e guardava, ao todo, seis tabletes e cinco porções de tetrahydrocannabinol (maconha), com peso líquido de 3.804,7 g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 38/40 e fotografia de fls. 41, para fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, Policiais Civis receberam uma denúncia anônima dando conta da prática do tráfico de drogas no endereço acima mencionado. Visando comprová-la, rumaram para lá e ficaram acampados por um breve período. Nesse meio tempo, ali compareceu Lucas de Souza Silva, ocasião em que adquiriu do réu uma porção de maconha. Tendo em vista a prática da traficância, os Policiais Civis rapidamente se dirigiram até o local e conseguiram abordar não só o réu, como também Lucas. Com

Lucas foi apreendida a porção de maconha que havia acabado de adquirir do réu. Leandro informalmente admitiu a traficância, confessando que, além da droga que tinha vendido para Lucas, tinha mais entorpecente em sua residência. Após ter sido franqueada a entrada no imóvel, não só por Leandro, mas também pela irmã deste, Samara Bernardino de Seixas Freitas, o réu indicou uma mochila, onde, em seu interior, os Policiais Civis encontraram seis tabletes de maconha e quatro porções de referido entorpecente, totalizando quase quatro quilogramas de referida droga. Ademais, com o réu foram apreendidos cento e vinte reais em notas diversas e dois celulares. Leandro e Lucas foram encaminhados até a Delegacia de Polícia, ocasião em que, formalmente, Lucas disse conhecer de vista o réu e saber que ele ficava no local dos fatos, ponto conhecido de comércio de drogas, exercendo a traficância. Disse que pagou ao réu a quantia de trinta reais pela maconha que havia acabado de adquirir. Já Leandro não quis se manifestar. A prévia denúncia anônima; a campana; o ato de venda de droga; a quantidade de droga; a detenção do usuário que havia acabado de adquirir entorpecente com o réu; a delação do usuário e a confissão informal do réu revelam que os entorpecentes se destinavam ao tráfico.

Por fim, o crime de tráfico de drogas foi praticado quando já vigorava o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, decreto este que "Reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas".

Denúncia recebida em 07 de outubro de 2021, citado o réu (fl. 137), constituiu advogada que apresentou resposta à acusação (fls. 121/122), seguindo-se a instrução, com três testemunhas e interrogatório ao final.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa arguiu nulidade do flagrante por invasão de domicílio, no mérito, salientou a confissão judicial espontânea de prática de crime de tráfico de drogas, para postular aplicação de pena mínima, com aplicação da causa especial de redução de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 em seu grau máximo, em regime inicial menos gravoso, observadas circunstâncias pessoais favoráveis.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de constatação prévia de fls. 38/40 indica 3804,7g de tetrahydrocannabinol.

Auto exibição e apreensão de fls. 12/13 relaciona, além da droga, a quantia de cento e vinte reais, um celular da marca LG e um celular da marca Positivo.

Fotografia dos objetos apreendidos à fl. 41.

Laudo de exame químico-toxicológico de fls. 156/158 resultou positivo para tetrahydrocannabinol.

Está provada a materialidade delitiva, tal como consta na denúncia.

Em fase inquisitiva, os policiais civis Tiago Santesso Felipe da Silva e Renato Echuya relataram que receberam uma denúncia telefônica anônima, referente a ocorrência de tráfico de drogas localizado na Rua Ismael Neri, 169, Santana, em frente a uma residência. Assim, rumaram ao local dos fatos e em breve campana, observaram um indivíduo recebendo valores e entregando algo para outro indivíduo.

Então, resolveram pela abordagem dos indivíduos, os quais foram submetidos à revista pessoal, sendo localizado com um deles uma pequena porção de maconha, que foi identificado como Lucas de Souza e Silva, o qual informou que era usuário e que havia comprado a droga do outro indivíduo. O outro indivíduo foi identificado como Leandro Bernardino de Seixas Freitas, o qual informou que estava vendendo drogas e que havia mais entorpecentes dentro de sua casa. Leandro e a irmã Samara Bernardino de Seixas Freitas, a qual estava na residência no momento da abordagem, franquearam a entrada dos policiais, assinando o termo de consentimento. Leandro mostrou a localização dos entorpecentes que estavam dentro de uma mochila, dentro da qual continham 6 tabletes de substância esverdeada similar a maconha, bem como, pequenas porções da mesma substância fragmentadas. Informaram que no momento da revista, Leandro esvaziou os bolsos, sendo localizada com ele a quantia de cento e vinte reais em notas diversas e 02 aparelhos celulares. Assim, foi dada voz de prisão a Leandro, onde foi conduzido juntamente com o Lucas até esta Distrital

apresentando a ocorrência à Autoridade Policial.

Lucas de Souza e Silva declarou que possui problemas de depressão e ansiedade, e compareceu ao local dos fatos para adquirir uma pequena porção de maconha para seu consumo pessoal. Informou que conhece de vista Leandro Bernardino de Seixas e sabe que ele fica naquele ponto conhecido de comércio de drogas exercendo a traficância. Ao efetuar a compra, foi surpreendido pelos policiais, juntamente com Leandro, que os detiveram, conduzindo-os à Unidade Policial. Assumiu que a pequena quantidade de droga é de sua propriedade para uso próprio, e que pagou por ela a quantia de trinta reais. Afirmou que trabalha como assistente de fotografia, freelancer, recebendo a remuneração mensal média de quinhentos reais.

O réu, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio.

Em audiência de instrução:

Lucas de Souza e Silva relatou que comprou drogas do réu, em seguida foram abordados por policiais, não se conheciam, ele foi indicado por amigos que compravam drogas com ele, maconha. A partir do momento em que viu os policiais armados, entrou em pânico e não se atentou mais aos fatos, recordando-se apenas que os policiais perguntaram ao réu se ele tinha mais drogas, porém, não se recorda o que ele disse, e em seguida os policiais entraram na casa dele.

Policial civil Renato Echuya relatou que a partir de "denúncia" dirigida ao plantão de investigadores, dirigiu-se à Rua Ismael Néri, até que observou um usuário comprando uma porção de drogas do réu, abordando o réu. O usuário era Lucas, o traficante era Leandro. A irmã dele chegou em seguida e autorizou a entrada na casa dele, e aos fundos, numa lavanderia, havia uma bolsa com cerca de quatro quilogramas de maconha. Ambos foram conduzidos para a delegacia. O réu foi preso em frente à residência dele. No momento em que foi abordado o réu não trazia mais drogas além daquela que havia repassado ao usuário, mas trazia dinheiro e dois celulares. Até então ignoraram aquele ponto de tráfico e não conheciam o réu.

No mesmo sentido o depoimento do Policial civil Tiago Santesso Felipe da Silva, confirmando que o réu foi surpreendido vendendo drogas a outro indivíduo, em frente à casa dele, na qual, aos fundos, foi apreendida significativa quantidade de maconha, na presença da irmã do réu, em local exato por ele indicado.

Sâmara Bernardino de Seixas Freitas, irmã do réu, disse que estava em sua casa, quando os policiais entraram com ele já algemado, dirigiram-se ao quarto dos fundos, conversaram com ele naquele cômodo, e só disseram que ele seria preso por tráfico. Não sabe se havia drogas naquele cômodo, "eles passaram com uma mochila".

Os policiais não pediram autorização, mas assinou termo de autorização, posteriormente, na delegacia.

O réu confessou que vendia drogas ao rapaz quando foi abordado, mas não autorizou os policiais a ingressarem em sua residência, dentro da qual guardava drogas para outro traficante, de quem costumava comprar drogas, há dois meses. Admitiu também ter vendido droga anteriormente para um amigo do rapaz que foi detido por ocasião do flagrante. Esteve preso durante um ano e seis meses por crime de tráfico. Mais recentemente foi condenado em Minas Gerais por crime de porte ilegal de arma de fogo.

Em que pese a versão do réu, conjugada com a de sua irmã, consta nos autos autorização por ela firmada para que os policiais ingressassem em sua residência, destacando-se que o douto advogado de defesa não apresentou qualquer questionamento em esfera da corregedoria policial por iniciativa da signatária daquele documento, sequer elaboração de boletim de ocorrência, ou mera comunicação de inconformismo perante a autoridade policial por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante.

Ou seja, após autorizar que os policiais apreendessem em sua residência as drogas que o próprio réu indicou-lhes, devidamente instruída, em audiência procurou corroborar eventual tese defensiva acerca de suposta nulidade do flagrante.

O julgamento a que se remete a tese de defesa, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sobre exigência de gravação de imagens ou autorização escrita do réu para que os policiais ingressassem em sua residência, ainda que em situação de flagrante de crime permanente, não recebeu efeitos gerais ou vinculantes, e contraria entendimento consolidado há décadas pelo mesmo tribunal, divergindo inclusive do

entendimento atual da 5ª Turma, no sentido de que o crime de tráfico, conduta de caráter permanente, consuma-se antes mesmo da interferência dos policiais, nas modalidades típicas guardar e trazer entorpecentes, para posterior entrega de qualquer forma a terceiros. A mesma temática já foi abordada até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, no RHC 53.659, circunstância que afasta qualquer ilicitude a macular a prova produzida.

Nesse sentido: "Violação de domicílio - Inocorrência - Ação policial intentada com o objetivo de efetuar prisão no interior de residência, em que se realizava comércio ilícito de entorpecente - Garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio que é inaplicável nos casos de flagrante delito - Inteligência do art. 5º, XI da Constituição Federal. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio cede espaço nos casos de flagrante delito (CF, art. 5º, XI), não merecendo censura a ação policial intentada com o objetivo de efetuar prisão no interior de residência em que se realizava comércio ilícito de entorpecente, em especial quando a entrada ocorreu sem arrombamento." (STJ - RT 771/565).

Em julgamento mais recente, publicação DJe 08/04/2021, a Egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou entendimento contrário ao julgado invocado pela defesa, do qual destaco trecho específico sobre o tema questionado:

AgRg no RHC 143123/MG, Relator Ministro Félix Fischer; Ementa: "TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato de os policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses."

Neste contexto, a prova da apreensão das drogas resulta dos relatos dos policiais, contra os quais não consta nenhum outro elemento de prova, sendo que, se de fato havia mais alguém dentro da casa, familiar do réu, cumpria à defesa arrolar como testemunha, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. Baseando-se em tais provas, sobre a validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, ao contrário do que sustentou a defesa em alegações finais, devem ser acolhidos como elementos de prova, eis que uníssonos e coerentes com o teor do auto de prisão em flagrante, prevalecendo a presunção de legalidade e veracidade de que se revestem os atos dos agentes públicos, constituindo ônus da defesa a prova em sentido contrário, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, e nesta ação penal não se tem qualquer indício de suspeição ou ilegalidade que possa macular o valor de tais depoimentos. Reporto-me ao entendimento jurisprudencial:

Prova criminal - Testemunha - Tráfico de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Inexistência de razão concreta para a suspeição - Relato firme e coerente - Apreensão da droga, ademais, presenciada por testemunha alheia aos quadros da polícia - Recurso não provido - JTJ 241/313. Crime contra a saúde pública - Prova criminal - Depoimento de policial participante de diligência do flagrante - Testemunho coerente e seguro - Validade - RT 595/423.

Em acréscimo a tais relatos, a testemunha civil arrolada no local dos fatos, confirmou que o réu praticava tráfico de drogas, habitualmente, sendo fornecedor de maconha para amigos seus.

Sendo assim, quanto ao elemento subjetivo do crime atribuído ao réu, inequivocamente, trazer consigo quase quatro quilogramas de substâncias entorpecentes caracteriza prova de mercancia ilícita, afastando-se a possibilidade da droga destinar-se a consumo pessoal.

Procedente a ação penal, nos termos da denúncia. Passo ao cálculo das penas. O réu Leandro Bernardino de Seixas Freitas ostenta condenação por crime de tráfico de drogas, com pena extinta há mais de cinco anos da data do fato, que não caracteriza reincidência nos termos do artigo 63 do Código Penal, devendo ser considerada como circunstância judicial desfavorável, em função da vida pregressa do criminoso, nos termos do artigo 59 do Código Penal, impondo-se acréscimo de 1/6 sobre a pena base, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta dias multa. A grande quantidade de droga apreendida, com potencial de dano difuso à saúde pública devido

ao amplo alcance de usuários, faz incidir a regra do artigo 42 da Lei nº 11.343, e por consequência, afasta a aplicabilidade da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, excluído o requisito subjetivo previsto em caráter excepcional para essa regra de cálculo da pena. Bem assim, a testemunha alheia aos quadros policiais confirmou em juízo que o réu praticava tráfico de drogas habitualmente e fornecia maconha a pessoas de seu convívio. A circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea J, do Código Penal, prevê circunstância objetiva da conduta, consistente em praticar crime em "qualquer calamidade pública", isto é, quem praticar crime em tal circunstância, independentemente de sua intensão, receberá tratamento legal diferenciado. O Decreto número 64879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo decorrente da pandemia do Covid-19, foi largamente divulgado por todos meios de comunicação, de conhecimento, sendo inviável alegar ignorância da situação atual de pandemia. Inequívoco, portanto, que a conduta de praticar tráfico de drogas durante a situação de calamidade pública representa risco ainda maior à saúde pública, pois, não atenta apenas contra a saúde daquele que consome a droga objeto material do crime de tráfico, mas, primordialmente, promove aglomeração de pessoas no local da prática do crime de tráfico, concorrendo para disseminação da doença e contágio coletivo, risco que o traficante assumiu e será apenado proporcionalmente à gravidade da conduta criminosa. Aplica-se acréscimo de pena de 1/6 em função da circunstância agravante, que deve ser reconhecida pelo juízo, nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, que totaliza as penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, e seiscentos e setenta dias multa. Não constam circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, e não caracterizada confissão judicial espontânea, porque o réu contrariou a narrativa da denúncia, ao negar a finalidade de mercancia para os quase quatro quilogramas encontrados no interior de sua residência, pretendendo delegar sua responsabilidade a terceiro, pessoa que sequer pretendeu identificar. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, e o tempo de prisão descontado desde a data do flagrante não é suficiente para antecipação de regime prisional menos gravoso, nos termos do artigo 112 da LEP, em aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal não é compatível com a quantidade de pena aplicada e a gravidade da conduta, ponderados os mesmos fundamentos da dosimetria da pena, tratando-se de conduta de consequências diferenciadas que atenta seriamente contra a ordem pública e acarreta manifesto risco à ordem e segurança pública, fomento de diversas atividades criminosas ainda mais graves, merecedora de tratamento legal diferenciado, em resguardo ao caráter preventivo da pena, para que sirva de efetivo desestímulo à reiteração da conduta pelo criminoso que se dispõe a distribuir drogas em bairro residencial densamente habitado, de modo a expor a risco não só os usuários como potenciais adquirentes de drogas ilícitas, mas principalmente todos aqueles que, alheios à sua atividade criminosos, são obrigados a conviverem diariamente sob a nefasta ameaça do tráfico de drogas. Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, não havendo prova de condição econômica do réu, como exige o artigo 60 do Código Penal. O réu foi preso em flagrante, permaneceu preso durante todo o curso do processo, e subsistentes os fundamentos da decisão de indeferimento da liberdade provisória ao início da ação penal, não se justifica a soltura incondicionada antes do início da execução penal. Fica indeferida a possibilidade de recorrerem em liberdade. Súmula nº 9 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que: "A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência". Se o criminoso respondeu preso ao processo, deve permanecer na mesma situação, sob pena de contrassenso, eis que a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, assim como as demais formas de prisão cautelar, não representam "pena antecipada", mas, sim, decisão de natureza cautelar sobre periculosidade do criminoso, servindo para resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, razão por que não se há de cogitar de violação do princípio constitucional da presunção de inocência.

Do exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar o réu Leandro Bernardino de Seixas Freitas, qualificado à fl. 16, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, seiscentos e setenta dias multa, pela fração legal mínima. Com fundamento no artigo 63, I, da Lei 11343/06, determino perdimento do dinheiro apreendido, produto de crime de tráfico, que será revertido ao FUNAD.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003).

Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Recomende-se-o na prisão em que se encontra, expedindo-se oportunamente guia de execução.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA